



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/8/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
מאיר פורת

התובעים:	1	שרון שביט רביבו
	2	שרון וולף רביבו
	באמצעות ב"כ: עו"ד גרשון שבתאי	
	נגד	
הנתבעים:	1	שטיגל מיכאל
	2	שטיגל לילית
	באמצעות ב"כ: עו"ד בן-דרור נלי	

פסק דין

תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק מהגג הצמוד לדירת התובעים את דוד השמש, עמודי התמיכה והקולטים של דירתם (להלן - "**דוד שמש**") וכן תביעה לחיוב הנתבעים בתשלום דמי שימוש בגג בגין הצבת דוד השמש.

העובדות הרלבנטיות להליך:

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב ראש פינה 23 פתח תקווה הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 26 גוש 7194 (להלן - "**הבית המשותף**"). בבית המשותף עשר קומות ו-34 דירות והוא שייך למתחם המונה 12 בניינים אשר נרשמו יחד בתאריך 25.05.2014 בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף לבית המשותף נרשמו צו ותקנון מוסכם (להלן - "**צו**" ו- "**תקנון המוסכם**").

2. התובעים 1 ו-2, שרון שביט רביבו ושרון וולף רביבו (להלן - "**התובעים**") הם הבעלים של דירת מגורים בבית המשותף הידועה כתת חלקה 212 הנמצאת בקומה הרביעית בבית המשותף. בהתאם לצו, הוצמד לדירת התובעים גג בשטח של 32.30 מ"ר הנמצא בקומה העשירית, ומסומן בתשריט ש32.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/8/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- הנתבעים 1 ו-2, שטיגל מיכאל ושטיגל לילית (להלן - "הנתבעים") הם הבעלים של דירת פנטהאוז הנמצאת בקומה התשיעית בבית המשותף הידועה כחת חלקה 230, הממוקמת מתחת לגג הצמוד לדירת התובעים.
3. כנטען בכתב התביעה שהוגש בתאריך 05.01.2021, דוד השמש ומתקניו המשרתים את הנתבעים, מותקנים על הגג העליון הצמוד לדירת התובעים. מכתבי התראה שנשלחו לנתבעים בבקשה להעתיק את דוד השמש מחוץ לגג המוצמד וניסיונות למצוא פתרון משותף למיקום אחר לא צלחו. לפיכך, עתרו התובעים לקבלת צו עשה לסילוק דוד השמש מחוץ לשטחם ותשלום בסך 51,500 ₪ הכולל דמי שימוש בסך 30,000 ₪, תשלום שכ"ט עו"ד עובר להגשת ההליך בסך 1,500 ₪ ו פיצוי בסך 20,000 ש"ח בגין עוגמת הנפש.
4. בכתב ההגנה שהוגש בתאריך 14.03.2021, נטען שיש לסלק את התביעה על הסף שכן הוגשה בחוסר תום לב וללא עילה, כתגובה להוצאת צו עצירת בנייה נגד התובעים, על ידי הנתבעים בתאריך 28.08.2020, לאחר שהחלו לבצע בגג עבודות בנייה ללא היתר כחוק. בנוסף, על הקונסטרוקציה הבנויה על הגג המוצמד לדירת התובעים מותקנים מלבד דוד השמש, 16 קולטים המשמשים מחצית מדיירי הבית המשותף. כך שנוכח העדר עילה וחוסר יריבות בין הצדדים ולאור העובדה כי התובעים במעמד רכישת דירתם ידעו על מיקומם של דוד השמש והקולטים על הגג שרכשו ולא התנגדו למצב הקיים, יש לדחות את התביעה.
5. בהחלטה מתאריך 28.04.2021 שניתנה בתום הדיון המקדמי שנערך, בו נשמעו טענות הצדדים ולאחר שנוכחתי כי המחלוקת בין הצדדים אינה עובדתית אלא משפטית, הורתי לצדדים להגיש רשימת הסכמות ופלוגתאות שתהא בהן כדי לסייע במתן פסק הדין וכן הורתי לתובעים להודיע, האם הם מבקשים לתקן את כתב התביעה על דרך הוספת סעד שעניינו הסרת יתר הקולטים המצויים בגג.
6. לאחר הודעת התובעים כי אינם מעוניינים להגיש כתב תביעה מתוקן להסרת יתר הקולטים מהגג, התמקד הדיון בשאלת הסרת דוד השמש של הנתבעים בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/8/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בתאריך 21.10.2021 הגישו התובעים רשימת מוסכמות ופלוגתאות מטעמם ובתאריך 03.01.2022 הגישו הנתבעים רשימת מוסכמות ופלוגתאות מטעמם.

8. מאחר שלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות משותפות, ומכיוון שלא הייתה בין הצדדים מחלוקת עובדתית הדורשת ניהול הליך הוכחות, נשמעו סיכומי הצדדים בעל-פה, בהתאם להוראות תקנה 74 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן- "**התקנות**"), בדיון שהתקיים בתאריך 31.01.2022.

9. בתום הדיון, ביקשו הצדדים שהות כדי להידבר ביניהם, אולם בתאריך 8.3.2022, הודיעו הצדדים כי הניסיון לסיים את המחלוקת בפשרה, לא צלח.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

10. על הגג הצמוד לדירת התובעים הותקנו דוד השמש והצנרת היורדת דרך רצפת הגג לדירת הנתבעים, המצויה בקומה התחתונה. הואיל והנתבעים לא רכשו זכות שימוש בגג הפרטי המוצמד לדירת התובעים, קמה לתובעים זכות, על פי סעיפים 16, 17, ו-21 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן- "**החוק**") או "**חוק המקרקעין**"), לדרוש לפנות את דוד השמש על מתקניו ולחייב את הנתבעים בעבור השימוש בקניינם.

11. בנטל השכנוע בתביעה לפינוי וסילוק יד ממקרקעין כלל הוא, כי התובע סילוק יד ממקרקעין מכוח בעלות בהם, די לו להוכיח עובדה זו בלבד, ומכאן ואילך מוטל הנטל על הנתבע להוכיח את זכותו להמשיך ולהחזיק במקרקעין.

12. אף על פי שבשטח התובעים מצויים מתקנים נוספים השייכים לדיירים אחרים לרבות מתקנים השייכים לרכוש המשותף, קיבלו התובעים הסכמה מנציגות הבית להזזת יתר המתקנים שמחזיקים את קולטי השמש. ברגע שאלו יועתקו, יישאר להעתיק את הדוד השייך לנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/8/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. לא עלה בידי הנתבעים הנטל להוכיח או להציג ראיה הסותרת את טענת התובעים כי דירתם נרכשה נקייה מכל חפץ כפי שמורה התשריט שהציגו התובעים בו לא מופיע דוד השמש.

14. הנתבעים הודו בהנחת דוד השמש על הגג הצמוד לחלקת התובעים. אף אם נניח כי "שתיקתם" של התובעים משך שנים ארוכות מהווה מתן הרשאה לשימוש בגג הבית, הרי שאפשר להתייחס לכך כהרשאת חינוס, ומשכך הרשאה זו אף אם ניתנה, היא ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון.

15. יש לקבל את התביעה ולהורות על צו עשה לסילוק או העתקת הדוד ומתקניו מחוץ לשטחם של התובעים, דבר הגורם להפרעה ופוגע בערך דירתם. דמי השימוש שנתבעו הם לתקופה של 12 חודשים מיום הגשת התביעה ובנוסף לאגרת בית המשפט יש לפסוק לטובת התובעים הוצאות הליך לרבות שכר טרחת עורך דין.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

16. זכות הבעלות היא זכות מוגבלת על פי הוראות סעיף 14 לחוק המקרקעין.

17. הפסיקה קבעה כי זכות הקניין בבית משותף מוגבלת ומצומצמת יותר ומתאימה את עצמה לתכונות המיוחדות של הבית המשותף.

18. המיקום להנחת דוד השמש והצנרת נקבעו על ידי החברה הקבלנית גינדי, שמכרה חלק מגג בבית המשותף לבעל הדירה הקודם אשר לא התגורר בקומה העליונה (ראו נספח ה' למוסכמות התובעים שנחתם בתאריך 11.07.2006) ולא על ידי מי מהצדדים.

19. התביעה חסרת עילה משפטית. כאשר התובעים רכשו את דירתם בתאריך 19.08.2013 מבעל הזכויות הקודם, עמדו דוד השמש והצנרת במיקומם הנוכחי (ראו תשריטי מכר שצורפו כנספח 2 לכתב ההגנה). במעמד הרכישה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/8/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצהירו התובעים כי ראו את הדירה ובדקו אותה ומצאו אותה מתאימה (סעיף 3.11 בנספח ד' למוסכמות התובעים) וכי הם רוכשים את המקרקעין AS IS ללא כל טענה (סעיף 4.1 בנספח ד' למוסכמות ופלוגתאות התובעים).

20. אשר לחוסר תום לב - התובעים עתרו לסעד הנתבע רק לאחר שהנתבעים פעלו באמצעים חוקיים לעצירת בניה בלתי חוקית שהחלו לבצע בגג. ידוע היה לתובעים כי דירתם והגג נרכשו ללא זכויות בנייה הניתנות למימוש (סעיף 8 לנספח ה' למוסכמות ופלוגתאות התובעים).

21. לאור האמור לעיל, הואיל וחובת תום הלב של התובעים במקרה דנא גוברת על זכותם הקניינית עת רכשו את הגג AS IS, יש לדחות על הסף את הסעד הנתבע להעתקת דוד השמש, וכן את הסעד לחיוב בדמי שימוש. שכן הסעד הראשי לא הוכח וגם אם היה עולה בידי התובעים להוכיח זאת, לא הוגשה חוות דעת על אודות גובה דמי השימוש הראויים. לפיכך, יש לפסוק לטובת הנתבעים את מלוא ההוצאות שנדרשו להם בהליך, לרבות שכר טרחת עורך דין כדין.

דיון והכרעה

22. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות. ואסביר.

זכות הבעלות בבית משותף או בבית שראוי להירשם כבית משותף, אינה זהה לזכות הבעלות הקלאסית בבית פרטי

23. לא בכדי קובע סעיף 2 לחוק המקרקעין בהגדירו את הבעלות, כי:

"הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם".

24. חוק המקרקעין בא לבשר על עידן שבו הבעלות או זכות אחרת במקרקעין נמדדות לא לפי החזקה ומספר השנים שהטוען לזכות מחזיק במקרקעין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/8/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלא על פי הרישום של הזכות הנטענת, למעט רכישת בעלות מכוח דיני ההתיישנות או זיקת הנאה מכוח שנים לפי סעיף 94 לחוק המקרקעין (ראו י. וייסמן – חוק המקרקעין התשכ"ט-1969: מגמות והשגים (1970)).

25. הרוכש דירה בבית משותף או בבית הראוי להירשם כבית משותף, צריך לדעת שרכש נכס עם מגבלות ולא בחלל ריק. היטיב לתאר זאת כב' השופט מישאל חשין אשר קבע (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו - 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994), להלן – "עניין צודלר") כי:

" הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה".

ובהמשך: "אכן, גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונם של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף."

26. זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית ולכן, יכול וזכות זו תהיה כפופה, בנוסף להגבלות לפי דין או לפי הסכם, לזכויות שימוש של אחרים בבית. כך לדוגמה, בדירות רבות בבתי משותפים עוברות צנרת הביוב והניקוז המשותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/8/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אשר היה ער לאפשרויות מסוג אלו בהגדירו בסעיף 52 לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע **"אפילו הם בתחומי דירה מסויימת"**. לאמור, בבית משותף ייתכן שרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו (ראו: (נתניה) 20-279 **איציק אלמוג נ' אמנון שלומוף** (נבו 27.12.2021).

27. השאלה העומדת להכרעה היא איזו מבין הזכויות גוברת בנסיבות המקרה דנא, זכותם הקניינית של התובעים או זכותם של הנתבעים להמשיך להשתמש בשטח התובעים על ידי המשך הצבת דוד השמש כפי שהוא מוצב בשטח זה שנים.

28. **במיושם לענייננו** – לא נסתרה טענת הנתבעים לפיה דוד השמש, המשמש את הנתבעים, מוצב בשטח הצמדת דירת התובעים בבית המשותף, מאז שהבית המשותף נבנה על ידי החברה הקבלנית (חברת גינדי) בשנת 2006, ועוד לפני שהתובעים רכשו את דירתם (ראו נספח ה' למוסכמות ופולגותאות מטעם התובעים).

29. התובעים רכשו את זכויותיהם בדירה במהלך שנת 2013 מהבעלים הקודמים (ראו נספח ד' למוסכמות התובעים) לה הוצמד שטח של 32.20 מ"ר בקומת הגג (ראו בנוסף לצו נסח רישום נספח א' לכתב התביעה), ולא נטענה מצד התובעים טענה לאי הסכמה או להתנגדות של הבעלים הקודמים או קודמיהם, לשימוש האמור של הנתבעים בגג המוצמד.

30. מנגד, רכשו הנתבעים את זכויותיהם בדירה מהחברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף, וקיבלו לידיהם חזקה בדירה עוד בשנת 2008 (ראו סעיף 6 לכתב ההגנה) כאשר בעת רכישתה, כללה הדירה את דוד השמש במיקומו הנוכחי עם 16 קולטים נוספים, המשרתים מחצית מכלל הדירות בבית המשותף.

31. במעמד חתימת התובעים על החוזה לרכישת הזכויות בדירה מהבעלים הקודם בתאריך 19.08.2013 הצהירו התובעים בסעיף 3.11 לחוזה הרכישה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/8/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(נספח ד' לפלוגתאות ומוסכמות התובעים), כי ראו את הדירה ובדקו אותה מבחינה פיזית, תכנונית ומשפטית ומצאו אותה מתאימה למטרות אשר לשמן קנו אותה וויתרו על כל טענה של אי התאמה, מום או ברירה, למעט פגם נסתר אשר היה ידוע למוכר והוא לא גילה לקונה. אין מחלוקת כי בעת הזו, דוד השמש של הנתבעים, היה ממוקם בשטח ההצמדה, לפחות כבר חמש שנים.

32. התובעים אף אישרו בפניי כי דוד השמש קיים על הגג הצמוד לדירתם מיום הקמת הבית (ראו עמוד 2 שורה 6 לפרוטוקול הדיון) וכי על הגג הצמוד לדירתם קיים בנוסף, מבנה עם עמודים עליו מותקנים 16 קולטים של 16 דיירים נוספים, מלבד דוד השמש נשוא התביעה (ראו עמוד 1, שורה 23 לפרוטוקול הדיון). יש לקבוע איפוא, שהתובעים רכשו את הדירה ואת הגג הצמוד לה עם דוד השמש המותקן על הגג.

33. מרקם החיים בבית המשותף הוא כזה, שבתוך דירות רבות מונחות תשתיות שונות שאינן משמשות בהכרח את בעל הדירה שבשטחו הן עוברות. כך למשל בכל הקשור לתשתיות חשמל, ביוב גז ומים, כך גם בכל הקשור לאנטנות, צלחות לוויין ודודי שמש הממוקמים על גגות אשר הוצמדו לדירה/לדירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר באותם מתקנים. [(המפקח על המקרקעין חיפה) 729/16 ח'ורי עפו נ' שאער מוניב, בפסקאות 38-40 (נבו 02.05.2019); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 493/19 חמרי עזרא נ' קטיעי קונסלסיון רונית (נבו 02.09.2021)].

הזכות להמשיך למקם את דוד השמש מכוח רשות מכללא

34. עוד טוענים התובעים שככל שניתנה לנתבעים רשות שימוש בגג דירתם, הגיעה העת לסיימה לנוכח רצונם שלהם להשתמש בגג לצרכיהם. יש לבחון, האם בטעמים אלו של התובעים כדי להביא לסיום הרשות שניתנה לנתבעים להשתמש בשטח הגג המוצמד. מיותר לציין כי שונים הם פני הדברים ממצב שבו רכש אדם זכויות בגג נקי, ורק לאחר מכן הולך אחד מבעלי הדירות בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/8/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף ומתקין על אותו גג דוד שמש או כל מתקן אחר לשימוש, במקרה זה, תקום לבעל הגג עילה לסילוק יד.

35. אכן ככלל, אף אם ניתנה בעבר הסכמה לשימוש ייחודי, יהיה זה בשטח המשותף או בהצמדה, לרבות הסכמה שבשתיקה, הרי שזו בבחינת רשות שימוש מכללא, אשר רשאי בעל הדירה בבית המשותף להביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי מקבל הרשות כי אין הוא מוכן עוד להמשיכה [ראו והשוו (ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידיים, פ"ד לא(3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); רע"א 259/99 חברת פליצה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001)].

36. אלא, שלכלל האמור, ישנם חריגים, לפיהם בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה [ראו והשוו רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין, פסקה 4 (נבו, 29.4.2014); ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח, פסקה 17 (נבו, 19.8.2015); בע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית, בפסקה ח (נבו 08.11.2012); רע"א 7244/13 צוריאל סאלם נ' עזבון המנוח גרשון ולכניסקי ז"ל, בפסקה 16 (נבו 18.02.2014); ע"א (חי') 13721-05-16 גבאי נ' הקש, פסקה 30 (נבו, 5.10.2016)].

37. ויפים הדברים שנקבעו על ידי כב' השופטת דפנה ברק ארז בעניין ע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש - חברה ממשלתית - עירונית לדיוור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ (נבו, 3.10.2017): "המונח 'רישיון במקרקעין' מתייחס להענקת זכות להחזקה ושימוש במקרקעין בתמורה או ללא תמורה, במפורש או מכללא. הרישיון אינו חלק מהזכויות המנויות בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אולם פסיקתו של בית משפט זה הכירה בו כמוסד המבוסס על שיקולים של צדק ומתאים למקרים מסוימים שבהם לא רכש המחזיק זכות קניינית במקרקעין לכל דבר ועניין. ככלל, רישיון במקרקעין הוא הדיר וניתן לביטול, אך ישנם מקרים שבהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. במקרים שבהם בעל הזכויות במקרקעין הציג בפני אדם מצג בנוגע לשימוש במקרקעין - אף ללא הסכם מפורש - יש מצבים שבהם ניתן להכיר בקיומו של רישיון 'מכוח השתק' לשם עשיית צדק בין הצדדים. לצורך כך,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/8/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נבחנו בפסיקה, בין השאר, כוונת הצדדים, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך, משך השימוש במקרקעין ועוד. כמו כן, נקבע כי לבתי המשפט נתון שיקול דעת רחב אף בקביעת הסעדים מכוחו של הרישיון – החל ממתן פיצוי כספי בגין ביטול הרישיון וכלה בקביעה כי הרשות בלתי הדירה ואינה ניתנת לביטול – והכל על-פי נסיבות המקרה הקונקרטי...”

38. כך גם במקרה שלפניי, שבו ניתנה לנתבעים הזכות להשתמש בשטח הגג המוצמד לצורך הצבת דוד השמש של דירתם בשלב ראשוני ומוקדם של רכישת דירתם מהקבלן, ועוד שנים לפני שהתובעים רכשו את זכויותיהם הקנייניות. בנסיבות אלו, נוצרה אצל הנתבעים הסתמכות שהלכה והתחזקה ככל שחלפו השנים, בלי שנשמעה כלפיהם כל טענה. בכך למעשה עוגנה זכות השימוש של הנתבעים בגג לצורך האמור; וכיום, פגיעה בזכות זו אינה דבר של מה בכך ותתאפשר רק מטעמים חריגים. הדברים נכונים ביתר שאת בנסיבות שבהן עסקינן במתקן שייעודו לצורך חיוני, אשר מוצב כאמור באותו מיקום זה שנים רבות.

39. מצטרף אני לדברים שנאמרו לאחרונה, על ידי חברתי, כב' המפקחת עינת מידן בלום, במסגרת פסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין חיפה) 510/20 כהן גבריאל נ' אלפסי אברהם (נבו 02.05.2022), אשר עסק בסוגיה דומה לסוגיה שלפניי: “בשים לב לאופיו המיוחד ולמבנהו של הבית המשותף, נדרשת התחשבות במכלול שלם של זכויות, צרכים ואינטרסים של בעלי הזכויות בבית המשותף, שעשויה במצבים מסוימים להביא להגבלה מסוימת בזכות הקניינית ולגריעה ממנה, כמתחייב לצורך הבטחת קיומו של יסוד השיתוף בבית המשותף. ביטוי להכפפת זכות הקניין מפני זכויות אחרות ניתן למצוא בין היתר בסעיף 52 לחוק המקרקעין הקובע שחלקים מהרכוש המשותף יכולים להימצא “בתחומי דירה מסויימת”, וכן בסעיף 4(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע חובתו של בעל דירה לאפשר כניסה של חברי הנציגות או אחר מטעמם לצורך ביצוע עבודות לאחזקת הרכוש המשותף. דוגמה נוספת ניתן למצוא בסעיף 2 לתקנון המצוי המגביל את זכותו של בעל דירה לעשות שינויים ותיקונים בדירתו כאוות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/8/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נפשו, ובמצבים מסוימים כפוף רצונו להסכמת בעלי הדירות, ברוב כזה או אחר "

ובהמשך:

"סיכומם של דברים, התובעים רכשו את זכויותיהם בדירה כשהן כפופות לזכותם של הנתבעים להשתמש בשטח הגג המוצמד לצורך הצבת דוד השמש של דירתם, ומטעם זה, יש לדחות טענת התובעים כי הנתבעים עומדים על זכות לא להם"

40. לפני סיום אציין, שלא שוכנעתי בטענת התובעים לקיומה של חלופה למיקום דוד השמש בחלק אחר של הגג. מעיון בחוות דעת מטעם אנשי מקצוע שהציגו התובעים, שבדקו האם אפשר להעביר את הדוד שמש והצנרת לגג אחר, היו הדעות חלוקות. בהצעה הראשונה, שנערכה על ידי גלעדי רונן בתאריך 21.05.2021, נקבע כי אפשר להעביר את הדוד שמש אך לא את הצנרת המחברת את דוד השמש לדירת הנתבעים מתוקף היותה מחוברת ישירות למרכזיה. בחוות הדעת השנייה, שניתנה בתאריך 18.06.2021 על ידי רון גלמור מחב' ת.מ.א הנדסה וייעוץ בע"מ, נרשם כי קיימות מספר חלופות להענקת מיקומו של דוד השמש, באמצעות מעקפים מורכבים כאלו אחרים.

41. מה עוד שאיני מוצא את דרישתם לביטול הרישיון לשימוש במקרקעין כלפי הנתבעים כדרישה סבירה, שעה שנותרו 16 קולטים על אותו הגג, וכלפיהם ממשיך להתקיים רישיון השימוש.

סיכום

42. הנתבעים יהיו רשאים להותיר את דוד השמש במיקומו הנוכחי על הגג הצמוד לדירת התובעים. לפיכך התביעה נדחת. לאור תוצאתי זו, מתייתר הצורך לדון בסעדים הנוספים (דמי שימוש ראויים ומניעת הנאה) כפי שתוארו במסגרת סעיף 24 לכתב התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/8/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. אין בדחיית התביעה, כדי לחסום בעתיד את התובעים לנקוט בהליך מתאים, כאשר יהיה בידם היתר בנייה כדין לבניה על ההצמדה ויהיה צורך בהעתקת הדוד, כולו או מקצתו.

הוצאות הליך

44. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

45. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

46. במסגרת בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו 30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/8/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

47. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את העניין, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין ובשים לב לכך שאמנם התביעה נדחתה במלואה, עם זאת הצדדים השכילו להגיע להבנות שהיה בהן לחסוך ניהול הוכחות, אני מורה על חיוב התובעים, יחד ולחוד, לשלם לנתבעים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 7,500 ₪, בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל
ניתן היום, 07.07.2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה